

1500605-15.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... o réu informou que estava realizando o tráfico de entorpecentes e que escondia as drogas no aparelho de ar-condicionado. Não encontraram dinheiro em seu poder. Ele aparentava estar sóbrio. Não o conhecia anteriormente a estes fatos. Afirmou que tem certeza que a sacola encontrada na residência era o objeto que o réu arremessou quando estava prestes a ser alcançado, pois estavam muito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500605-15.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500605-15.2020.8.26.0536 - Controle n.º 181/20

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GERSON RIBEIRO MAIA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

GERSON RIBEIRO MAIA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 20 de fevereiro de 2020, na Avenida Professor Aristóteles Menezes n.º 20, confluência com a Praça Winston Churchill, bairro Ponta da Praia, neste município e comarca, trazia consigo 28 (vinte e oito) porções de cocaína (cerca de 10,1g) para a entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de p. 08 e auto de constatação preliminar de p. 7).

Diz a denúncia que o COPOM irradiou a notícia de que um indivíduo estaria armazenando drogas no vão de um ar-condicionado instalado na parte externa do "Mar Azul" localizado no endereço citado. Policiais militares foram até o local e avistaram o acusado, que, ao perceber a presença da polícia, começou a correr para fugir dali.

Durante a perseguição, o acusado colocou um saco preto que trazia consigo dentro da boca e, quando estava prestes a ser detido, tirou esse saco da boca e o arremessou no telhado da garagem de uma casa.

Diz a denúncia que, depois da abordagem do réu, os policiais subiram no telhado e

apreenderam o saco preto por ele arremessado. Dentro desse saco havia 28 (vinte e oito) porções de cocaína. Em revista pessoal, nada foi encontrado.

Diz, por fim, que a quantidade de entorpecente apreendido, aliada à sua natureza e às circunstâncias da apreensão evidenciam que o acusado trazia consigo drogas para fornecê-las a terceiros (pp. 42/44).

Notificado o réu (p. 61), seu Defensor ofereceu a defesa prévia de p. 187. Presente justa causa para o processamento da ação penal, foi recebida a denúncia (pp. 88/90), citando-se o acusado (p. 112). Processou-se, em apenso próprio, incidente de verificação de dependência toxicológica.

Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, procedendo-se ao interrogatório (gravação audiovisual, pp. 137/140).

À vista do apurado na fase instrutória, processou-se *mutatio libelli*, oferecendo o Ministério Público o aditamento de pp. 138/139, para desclassificar a acusação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Recebido o aditamento, o réu aceitou e teve homologada a proposta de transação penal (p. 139), mas a medida foi desconstituída (p. 178), retomando-se o curso desta ação penal.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos narrados no aditamento (gravação audiovisual de pp. 137/140 e p. 174).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações escritas, requereu a absolvição pela atipicidade da conduta em razão da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, por não causar ofensa à saúde pública, bem jurídico tutelado (pp. 180/186).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente o pedido de condenação pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do crime está satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (p. 6), pelo auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (p. 7) e pelo laudo de exame toxicológico (pp. 77/79).

A autoria desses fatos delituosos também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, e apesar da acusação que lhe era dirigida, o acusado manteve-se calado, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias que ensejaram sua prisão (pp. 11/12).

Em juízo, ao ser interrogado, afirmou que foi processado por extorsão mediante sequestro e porte de munições. Disse que não conhece os policiais e nada tem contra eles. Contou que sofre com a dependência de drogas desde os 18 anos de idade. Já fez uso de crack, álcool e cocaína. Informou que na data em que foi preso havia recebido seu salário e foi até o cais e lá adquiriu trinta unidades de cocaína por cinco reais cada. Disse que arrancou um pedaço de um plástico preto que envolvia um aparelho de ar-condicionado para embrulhar seus entorpecentes. Nesse momento chegaram os policiais militares. Afirmou que as drogas que adquiriu continham embalagens diferentes umas das outras. Por este motivo, somado ao fato de estar embriagado e não querer perder os entorpecentes, tentou fugir do policiais. Esclareceu que não pretendia guardar as drogas naquele local. Já tinha separado duas porções para seu consumo imediato. Pretendia seguir para sua casa após comprar bebidas alcoólicas no posto de combustíveis. Informou que luta contra o vício desde 2007. Faz tratamento para se livrar da dependência química, mas continua tendo recaídas mesmo após sua prisão. Reside em casa própria com sua esposa e filha. Possui quatro filhos com três mulheres diferentes. Os menores contam 8 e 4 anos, além da recém nascida, que ainda passa por exames para confirmar se contém a síndrome de Down. Cursou o ensino médio. Está desempregado e realiza serviços esporádicos em mercados (gravação audiovisual pp. 137/140).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Josimar Serafim Martins, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento quando o COPOM informou que um indivíduo havia sido visto escondendo entorpecentes, que seriam destinados à venda. Deslocaram-se ao endereço informado e viram o réu próximo ao aparelho de ar-condicionado, com uma sacolinha em mãos. Ele tentava

colocar a sacola dentro do aparelho de ar-condicionado de janela. A janela ficava na lateral do posto de combustíveis em funcionamento. Esclareceu que foram em direção ao acusado que, ao perceber a aproximação da equipe, colocou a sacola na boca e iniciou fuga, sendo perseguido pela equipe policial, que se deslocava com motocicletas. Relatou que quando o acusado percebeu que seria detido, retirou o objeto de sua boca e arremessou no telhado de uma residência. Em revista pessoal nada encontraram com ele. Ao vistoriarem o objeto lançado na residência encontraram vinte e oito porções de cocaína. Na ocasião o réu informou que estava realizando o tráfico de entorpecentes e que escondia as drogas no aparelho de ar-condicionado. Não encontraram dinheiro em seu poder. Ele aparentava estar sóbrio. Não o conhecia anteriormente a estes fatos. Afirmou que tem certeza que a sacola encontrada na residência era o objeto que o réu arremessou quando estava prestes a ser alcançado, pois estavam muito próximos a ele. Explicou que o COPOM recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo estaria escondendo drogas no aparelho de ar-condicionado do posto de combustíveis. Indagaram um frentista, que negou conhecer o acusado, afirmando que não o tinha visto ali outras vezes. Não havia outras pessoas no local no momento da prisão (gravação audiovisual pp. 137/140).

Marcel Bomfim da Silva, policial militar, disse que foram informados pelo COPOM que indivíduos estavam no posto de combustíveis Mar Azul, guardando entorpecentes no aparelho de ar-condicionado. Deslocaram-se até o local e viram o réu próximo ao ar-condicionado. No momento em que ele percebeu a presença da equipe policial, colocou um saco plástico em sua boca e fugiu. Disse que o perseguiram e, quando estavam prestes a alcançá-lo, ele arremessou o saco que estava em sua boca em cima do telhado de uma garagem. Em revista pessoal nada ilícito encontraram em seu poder. Ao vistoriarem o saco plástico arremessado encontraram aproximadamente vinte e oito papéletes de cocaína. Indagado, o réu afirmou que a droga era para consumo próprio. Em nenhum momento disse que estaria ali comercializando drogas. Não encontraram em seu poder outros objetos que indicassem ser ele usuário e drogas (gravação audiovisual pp. 137/140).

Vê-se, assim, que a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório, não sendo possível declarar a absolvição.

O acusado admitiu a conduta delituosa em sede judicial, afirmando que possuía as porções de cocaína encontradas em seu poder e que eram para seu consumo pessoal. Ademais, sob o crivo do contraditório, os policiais militares foram firmes em relação à apreensão das porções de entorpecentes, não se evidenciando mácula no seu relato em relação a esse aspecto.

Ao revés, de forma isenta, informaram os principais detalhes a respeito da abordagem e apreensão das porções de cocaína encontradas em poder do réu. Tudo indica que os policiais militares agiram com lisura ímpar e, por certo, não se poderia desacreditar seus relatos, uma vez que apenas tais agentes presenciaram os fatos, não se podendo entender como suspeitos aqueles que são investidos de poder para tal função.

E, como já se decidiu:

"É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (HC 87662, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007).

"... A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário..." (TJSP; Apelação Criminal 1500453-63.2018.8.26.0559; Relator(a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2021).

Desta forma, certo está que a confissão – manifestada na fase judicial – encontra seguro conforto na prova aqui reunida sob o contraditório, que indica o desate

condenatório.

Por final, destaque-se que não há como reconhecer que a posse ilegal de droga destinada a consumo pessoal seja conduta atípica, em razão da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, como alegado.

Apura-se conduta delituosa que afronta e põe em risco a saúde pública, evidenciando-se patente o risco social, bem como se revela potencial e abstrato o dano decorrente do consumo de entorpecentes, pouco importando a lesividade configurada pela quantidade de droga apreendida em cada caso concreto.

Trata-se, por certo, de norma penal que tutela a saúde pública, sendo irrelevante discutir se a repressão ao consumo de entorpecentes, sem autorização legal, representa invasão à privacidade do cidadão.

Não fosse isso, não há dúvida que deve o Estado criminalizar o consumo ilegal de drogas, já que a saúde pública é posta em risco em razão da conduta individualmente considerada. Essa situação é penalmente relevante e, assim, há de ser reprimida.

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, alegando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Descabimento. Absolvição. Impossibilidade.

Constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas é típica, não se vislumbrando a alegada violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade. Não apenas o uso propriamente que caracteriza mais seriamente o delito, mas a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para aquela finalidade. O bem jurídico protegido é a saúde pública, em razão do risco que lhe é inerente. A lei não trouxe a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal, mas apenas a despenalização, a fim de conferir ao usuário de drogas tratamento diverso daquele endereçado ao traficante. Inconstitucionalidade não verificada. O Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, do C. Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas, está suspenso.

Observância do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10. Condenação acertada, ora mantida. Negado provimento. " (TJSP; Apelação Criminal 1500037-11.2019.8.26.0608; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 23/06/2020).

Nesse mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... É inviável a declaração da atipicidade da conduta do paciente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Embora a constitucionalidade do referido artigo esteja afetada na Suprema Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral (Tema 505), nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/RG, ainda prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas para o infrator..." (HC 535.785/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019).

Outrossim, extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"... A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III – No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV – É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V – A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI – Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII – Habeas corpus

prejudicado." (HC 102940, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011).

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório, reconhecendo-se a prática do delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Procede, portanto, o pedido inicial.

Passo à individualização da pena.

O acusado é primário (certidão de pp. 135/136).

Diante das penas enumeradas na legislação, imponho ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 2 (dois) meses, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Observo que não é caso de se impor ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos da droga, isso porque não parece que a medida mencionada seja suficiente e necessária à reprovação da conduta aqui apurada.

Note-se que o réu foi detido enquanto trazia consigo 28 porções de cocaína (10,1 g). Assim, em razão da quantidade e da lesividade das drogas apreendidas, essa medida parece inócua para a reinserção social e percepção dos maléficos efeitos do consumo de drogas.

Aliás, é importante considerar que a legislação prima pela prescrição de "...medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção do usuário e dependente de drogas..." (artigo 1º, caput, da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar GERSON RIBEIRO MAIA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, pena essa a ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, por incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 24 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA